

1502766-37.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306396/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 21313868 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3595/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2306396

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502766-37.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502766-37.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306396/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 21313868 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3595/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2306396

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIEBERTY WILLIAN ALVES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Hieberty Willian Alves dos Santos e Marcos Júnio Vieira Paschoal foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo denúncia (fls. 75/76), no dia 10/11/2021, às 01h10min, na Rua Caçapava, nº 220, Vila Carmela, em Franco da Rocha, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, traziam com eles, para fins de entrega ao consumo alheio, 36 porções de cocaína (Hieberty) pesando, aproximadamente, 35g de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 09), laudo de constatação (fls. 11/13) e laudo toxicológico definitivo (fls. 68/70), bem como a quantia de R\$ 250,00 em notas trocadas. A denúncia foi recebida em 13/12/2021 (fl. 79).

Citados (fls. 104, 105 e 151), os réus apresentaram resposta à acusação (fl. 113). Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas e o réu Hieberty foi interrogado ao final; foi decretada a revelia do réu Marcos Júnio, o qual não compareceu na audiência (fl. 152).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, tecendo considerações sobre a pena (fls. 173/177). A defesa requereu a desclassificação para o delito de uso de substância entorpecente e, subsidiariamente, a aplicação de pena no mínimo legal (fls. 182/242).

É o relatório.

Passo a decidir.

Preliminarmente, há que se esclarecer um ponto a fim de evitar pretensa declaração de nulidade. Nos termos do art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, o juiz que encerrar a instrução “deverá” proferir a sentença. Trata-se, obviamente, de recomendação que deve ser observada sempre que possível, em atenção ao princípio da identidade física do juiz, que atualmente vigora no Processo Penal, mas que encontra exceções em casos de manifesto impedimento do Magistrado.

In casu, verifica-se que a Juíza não está mais atuando nesta Vara, razão pela qual os autos foram conclusos a este juízo, não havendo, portanto, violação ao princípio da identidade física do juiz, por aplicação analógica do disposto no art. 132, do Código de Processo Civil.

Confira-se, a propósito:

Mesmo que tenha concluído a audiência, o Magistrado não terá o dever de julgar a lide se for afastado do órgão judicial, por motivo de convocação, licença, cessação de designação para funcionar na vara, remoção, transferência, afastamento por qualquer motivo, promoção ou aposentadoria. Incluem-se na exceção os afastamentos por férias, licença-prêmio e para exercer cargo administrativo em órgão do Poder Judiciário (Assessor, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça etc) (Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 11ª edição, pag. 411).

“...Segundo o Princípio da Identidade Física do Juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP (modificação trazida pela Lei nº 11.719/08), o Magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito. III - No entanto, em razão da ausência de regras específicas, deve-se aplicar por analogia o disposto no art. 132 do CPC, segundo o qual no caso de ausência por convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria, deverão os autos passar ao sucessor do Magistrado. IV 'A adoção do princípio da identidade física do Juiz no processo penal não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos que pretendem se furta à aplicação da Lei.' (CC 99023/PR, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 28/08/2009). V - Ademais, no sistema das nulidades pátrio, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos (Precedentes). Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada” (STJ, HC 163.425/RO, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 27.5.2010, p. 6.9.2010).

“APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DIVERSAS VEZES NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INOCORRENTE REGRA QUE ADMITE EXCEÇÃO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PRELIMINAR ARREDADA (...) RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (...) Portanto, embora realmente o ilustre Magistrado que proferiu a sentença não tenha sido aquele que presidiu a instrução, é de se presumir que a sucessão nestes autos ocorreu de modo regular. Ao menos, nada sugere ofensa às normas aplicáveis, até mesmo porque não demonstrou a defesa eventual prejuízo suportado com a alegada irregularidade.” (Apelação Criminal 1500094-45.2019.8.26.0441; Rel. Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 28/05/2021).

Apelação Criminal – Recurso defensivo – Estupro de vulnerável – Preliminar de ofensa ao princípio de identidade física do juiz – Afastada – Regra que admite exceção – Prejuízo não demonstrado (TJSP; Apelação Criminal 0003538-59.2017.8.26.0271; Rel. Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de

Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022).

Furto qualificado - Princípio da identidade física do juiz - Violação - Inocorrência - ausência de prova no sentido de que a Magistrada que encerrou a instrução estivesse em exercício por ocasião da sentença - Prejuízo, ademais, não demonstrado - Preliminar rejeitada; Furto qualificado - Negativa da acusada em juízo - Alegação de que efetuava as retiradas com anuência e ordem de superior hierárquico - Possibilidade de cometimento de crimes diversos do narrado na denúncia - Indícios trazidos com o inquérito não confirmados em juízo - Aplicação do princípio in dubio pro reo - Absolvição mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0087347-33.2014.8.26.0050; Rel. Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021). Superado o tema, e ainda em sede preliminar, não há que se falar em irregularidade da atuação dos guardas municipais.

Como sabido, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Nesta categoria de infrações, o sujeito pratica uma violação da norma penal que se prolonga no tempo. Estará, portanto, em constante estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminoso (art. 303 do CPP).

O Código de Processo Penal, em seu art. 301, permite que qualquer pessoa do povo efetue prisão de quem se acha em flagrância delitiva. É cediço que o art. 144, §8º, da Constituição Federal determina que a Guarda Municipal será destinada à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo, portanto, como principal função a de assegurar a segurança pública, tampouco investigar a prática de crimes. Nada obstante, a referida disposição não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante aquele que estiver cometendo um delito. Tal entendimento não discrepa da posição consolidada pelos Tribunais Superiores: "Nos termos do art. 301 do CPP, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato da prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda Municipal não revela ilegalidade" (STJ, HC nº 394.112/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 03/08/2017).

Conforme o art. 144, §8º, da Constituição, é competência específica das guardas municipais colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social (art. 5º, IV), bem como encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração penal (art. 5º, XIV).

Neste caso, os guardas estavam em regulares diligências quando depararam-se com o réu Marcos, que segundo relatos empreendeu fuga ao ver os agentes e o réu Hieberty, que também segundo relatos dispensou uma sacola ao ver os guardas, em possível indicação de que estariam realizando prática criminoso. Não foram realizadas diligências prévias ou desvio da atuação, não havendo nulidade a amparar a alegação da defesa.

A pretensão punitiva estatal é IMPROCEDENTE.

A materialidade do delito restou comprovada diante do: auto de exibição e apreensão (fl. 09), laudo de constatação preliminar (fls. 11/13), laudo químico-toxicológico (fls. 68/70), boletim de ocorrência (fls. 162/164), auto de prisão em flagrante (fl. 01) e, por fim, pela prova oral colhida em regular instrução.

Quando ouvido perante a autoridade policial, o réu Hieberty negou os fatos. Disse que já foi preso/processado por roubo, duas vezes (uma em 2015 e outra enquanto menor de idade). Afirma que estava no local para comprar um pó, pois é usuário de maconha e cocaína. Alega que estava na via pública, quando foi abordado pelos guardas municipais. Aduziu que não trazia nenhuma droga consigo, apenas a quantia de R\$ 20,00, que seria para comprar drogas para uso pessoal. Esclareceu que os guardas municipais localizaram a droga em outro local, negando a propriedade das substâncias (fl. 05).

Em juízo, o réu Hieberty negou os fatos. Disse no dia dos fatos, algumas horas antes do ocorrido estava numa festa com colegas próximo ao local dos fatos. Foi ao local dos fatos para comprar droga e ao chegar lá viu duas viaturas. Marcos gritou para os meninos que estavam vendendo drogas correrem. A viatura lhe abordou, não

foi abordado pelos policiais que prestaram depoimento. Com ele foram encontrados um celular, R\$ 20,00 e um maço de cigarro. Também enquadraram o Marcos, que estava descendo o escadão. Não encontraram nada com ambos, os colocaram numa viela ao lado de um barzinho e começaram a pressioná-los sobre se havia droga. O réu explicou que tinha passagem e que não sabe de onde veio a droga que foi encontrada. Disse que estava numa festa na Avenida da Saudade com amigos e que depois que foi preso não teve contato com a sua família, motivo pelo qual não conseguiu entrar em contato com seus amigos. Disse que não conhecia os GCMs de abordagem anterior. Disse que não estava com nenhuma sacola preta em suas mãos, apenas seu celular. Disse que não saiu correndo quando viu as viaturas, até porque estava com um problema no tornozelo e não tinha como correr. Afirmou que foi sozinho comprar droga e que não conhecia Marcos. Não sabe dizer se Marcos estava com drogas ou dinheiro, porque foi abordado do outro lado da rua. Afirmou que é usuário e que ficou sabendo que a Rua Caçapava é ponto de tráfico na festa. Mesmo vendo os meninos correndo, continuou subindo a rua. Disse que não deu tempo de comprar a droga e que é usuário de maconha e cocaína. Disse que dos guardas que o abordaram, se lembra bem de um, que era careca e mais baixo e branco. Tinha outro parecido com o que deu o primeiro depoimento desta audiência, mas era bem mais alto. Isso da 1ª viatura. Na 2ª viatura se lembra que tinha um grandão moreno e que não se recorda dos outros. Disse que não se recorda se as testemunhas estavam presentes na ação. Disse que tinham uns 8 guardas.

O réu Marcos, em solo policial, confessou parcialmente os fatos. Disse que nunca foi preso/processado e que em relação aos fatos alega que estava no local "trabalhando" como olheiro. Esclareceu que estava nessa função há 2 dias e que ganha a quantia de R\$ 100,00 por dia. Nega que estivesse na posse de qualquer droga, sendo que trazia consigo apenas a quantia de R\$ 2,00. Alega que seria o responsável por avisar quando a polícia chegasse no local (fl. 04). Marcos não compareceu em juízo, razão pela qual não foi efetuado seu interrogatório judicial.

A testemunha Walter Simão da Silva (GCM), em solo policial, disse que estava, juntamente com seu colega, ora testemunha, realizando patrulhamento pela Rua Caçapava, conhecido ponto de tráfico, quando visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como Hieberty e Marcos, em atitude que causou suspeita. Ao se aproximarem com a viatura, o indiciado Marcos tentou empreender fuga. Porém, logo foi abordado pelo condutor. Em busca pessoal, não localizou nada de ilícito com o indiciado Marcos, que teria admitido que estava no local exercendo as funções de "olheiro" e que ganharia o valor de R\$ 100,00 por noite para tal função. Já o indiciado Hieberty arremessou uma sacola preta em uma máquina de lavar que estava na calçada (material de reciclagem), sendo logo abordado por seu colega, ora testemunha. Na referida sacola trazida por Hieberty, havia 36 eppendorfs de cocaína e a quantia de R\$ 250,00. Mediante conversa informal, Hieberty admitiu a propriedade das drogas, assumindo que estava no local traficando, pois estava "passando necessidade" (fl. 02).

Em juízo, a testemunha Walter disse que é guarda municipal e, no dia dos fatos, estava em patrulhamento preventivo por uma rua que é ponto de venda de drogas conhecido. Quando a viatura foi vista pelos réus, estes empreenderam em fuga. Foram alcançados e abordados. Com o réu Marcos nada foi encontrado. Já o réu Hieberty foi visto dispensando uma sacola preta dentro de uma máquina de lavar para reciclagem que estava na calçada. Em conversa informal com o Hieberty, este informou que estaria traficando por estar passando necessidades em virtude de seu desemprego. Também em conversa informal com o réu Marcos, este estava fazendo o trabalho de "olheiro" e recebia R\$ 100,00 por noite; em seu bolso foi encontrado um eppendorf de cocaína. Na sacola tinha a quantia de R\$ 150,00, em notas de 100, 20 e 5 reais e uma quantidade de 36 eppendorfs. Ao ser indagado pela defesa o motivo pelo qual inicialmente a testemunha disse que nada havia sido encontrado com Marcos, disse que se recordou de ter encontrado um eppendorf de cocaína com Marcos. Dentro da sacola a única substância que havia era cocaína (fl. 153).

O depoimento em solo policial da testemunha Luan Bernardes dos Santos (GCM) foi no mesmo sentido daquele prestado por seu colega de farda. Disse que estava, juntamente com seu colega, ora condutor, realizando patrulhamento pela Rua

Caçapava, conhecido ponto de tráfico, quando visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como Hieberty e Marcos, em atitude que causou suspeita. Ao se aproximarem com a viatura, o indiciado Marcos tentou empreender fuga. Porém, logo foi abordado por seu colega, ora condutor. Já o indiciado Hieberty arremessou uma sacola preta em uma máquina de lavar que estava na calçada (material de reciclagem), sendo que realizou a abordagem e, na referida sacola, que visualizou sendo arremessada por Hieberty, havia 36 eppendorfs de cocaína e a quantia de R\$ 250,00 (fl. 03).

Em juízo, a testemunha disse que estava em patrulhamento pelo local, que é conhecido ponto de tráfico, quando os réus avistaram a viatura e empreenderam em fuga. Hieberty arremessou uma sacola preta dentro de uma máquina de lavar que estava num ponto de reciclagem. Dentro da sacola estavam 36 eppendorfs de cocaína e R\$ 250,00 em notas trocadas. Com o réu Marcos foi encontrado um eppendorf de cocaína. Em conversa com os réus, Hieberty disse que estava ali por necessidade. O Marcos disse que estava como olheiro ali e ganhava R\$ 100,00 por noite. O Hieberty admitiu o tráfico, que estava realizando a venda por necessidade. Disse que foi a testemunha Walter que revistou o réu Marcos. Disse que viu o momento em que foi encontrado o pino de cocaína com Marcos (fl. 154).

A despeito dos indícios iniciais, entendo tratar-se de hipótese de absolvição dos acusados. Os guardas indicaram que eles teriam confessado a traficância. No entanto, em seu interrogatório, o acusado Hieberty negou esse fato, enquanto Marcos não compareceu na audiência.

Ainda que pudesse ser consideradas as confissões informais realizadas perante os agentes de segurança, seria necessária que aquelas viessem amparadas por outros elementos que indicassem que os entorpecentes estavam, de fato, sob a guarda ou posse dos réus.

Quanto ao réu Marcos, em solo policial os GCMs disseram nenhuma droga havia sido encontrada com este. Mas em juízo afirmaram que foi encontrado um pino de cocaína com Marcos.

Frisa-se que não laudos periciais não constam a quantidade de eppendorfs de cocaína encontrados.

Depreende-se que o cenário delineado nos autos, no qual se construiu a imputação delitiva que recai sobre os réus não foi confirmado em juízo, razão pela qual revela-se permeado de divergências e dúvidas. Seus elementos fundadores, como se verifica, não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório, sendo, portanto, inaptos a ensejar a condenação dos réus pela prática do crime indicado em inicial.

Um dos princípios basilares do processo penal é que o processo-crime existe no interesse da busca da verdade real e, havendo qualquer dúvida entre o direito à liberdade dos acusados – e o direito de apenar do Estado-acusaçao, deve-se resolvê-lo em favor dos réus, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, absolvo os réus Hieberty Willian Alves dos Santos e Marcos Júnio Vieira Paschoal, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP.

Os réus poderão aguardar o trânsito em julgado em liberdade, caso não estejam presos por outro processo. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em jugado, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Defiro ao réu a gratuidade de justiça

P. I. C.

Franco da Rocha, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA